

1000723-17.2018.8.26.0666
Classe: Ação Civil Pública
Assunto: Dano ao Erário
Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO
Comarca: Artur Nogueira
Foro: Foro de Artur Nogueira
Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira
Data de Disponibilização: 02/09/2022

... funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento de interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos" (Pazzaglini Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35).
Disciplinando o tema, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Artur Nogueira
Foro de Artur Nogueira
Vara Única
Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira - SP - cep 13160-170
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000723-17.2018.8.26.0666 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1000723-17.2018.8.26.0666
Classe - Assunto
Ação Civil Pública - Dano ao Erário
Requerente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Requerido:
Margareti Rose de Oliveira Groot e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário e pedido de liminar contra Associação Beneficente Samaritano, Graciane Teixeira, Jordana Aparecida de Oliveira, Leonora da Silva Rocha e Margareti Rose de Oliveira Groot. Alega o autor ter a presente ação por objeto a condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa e ressarcimento de prejuízos causados ao erário, ante a sentença transitada em julgado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proferida nos autos do TC-002534/003/09, apenso ao TC-002185/003/09, que julgou irregulares a Concorrência Pública n.º 001/2009 e o contrato. No caso em apreço, a requerida Margareti determinou, em 28 de julho de 2009, a abertura do processo licitatório de nº 2118/2009, na modalidade de Concorrência Pública nº 001/2009, para a contratação de empresa para prestação de serviços de suporte médico e hospitalar e fornecimento de pessoal médico para a Policlínica Municipal, sendo designadas como membros da Comissão de Licitações, para a execução do procedimento, as requeridas Jordana, Graciane e Leonora. Resultou desse processo de licitação, em 21/09/2009, a contratação, mediante o contrato nº 078/2009, da requerida Associação Beneficente Samaritano (então Hospital e Maternidade Saint Paul), para prestação de serviços

médico-hospitalares, no valor de R\$ 2.520.000,00 pelo prazo de 12 meses. Em 21/09/2010 foi realizado o primeiro aditamento contratual, por mais 12 meses e pelo valor de R\$ 2.520.000,00. O segundo aditamento foi realizado em 21/09/2011, pelo mesmo valor e prazo. Em 20/09/2012, o Contrato nº 078 foi aditado por mais 12 meses, com supressão de 23 de seu objeto, perfazendo o valor de R\$ 2.173.248,00. Entretanto, em 05/12/2012 a segunda requerida deu ciência ao Município que não tinha mais interesse na manutenção do ajuste, requerendo a rescisão do Contrato nº 078/2009. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sentença transitada em julgado, julgou irregulares a Concorrência Pública nº 001/2009 e o Contrato nº 078/2009 e, por consequência, seus aditivos. Afirmou o Tribunal de Contas ter havido indevida terceirização de atividades típicas do poder público; violação à Lei nº 8.666/93 e aos princípios básicos da licitação e da administração pública. Diante disto, o Município, ora autor, requer a desconsideração da personalidade jurídica da Associação Beneficente Samaritano; o deferimento de medida liminar inaudita altera pars, de modo a tornar indisponíveis os bens dos réus até o valor de R\$ 9.084.808,33, para garantir o ressarcimento dos danos aos cofres públicos e o pagamento de multa; o pronunciamento jurisdicional definitivo para reconhecimento dos atos de improbidade administrativa supostamente praticados pelos demandados; em responsabilidade solidária, a condenação ao ressarcimento integral aos cofres públicos municipais do dano ou perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio pela ré beneficiária, consistente no valor global anual de R\$ 9.084.808,33, com os devidos acréscimos de correção e juros, desde a data de desembolso dos valores até o efetivo pagamento; a perda da função pública, quando o caso; a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos; o pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano, quando não se tratar de agente público; a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos; pagamento de multa civil de até 100 o valor da remuneração percebida pelo agente público (fls. 01/27). Juntou documentos (fls. 28/964).

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT DE GOES foi devidamente citada (fl. 1058) e apresentou defesa prévia (fls. 1075/1084). Alegou a ocorrência de prescrição. Afirmou que a sentença do Tribunal de Contas não pode ser utilizada como prova absoluta. Impugnou as alegações da inicial e a inexistência de improbidade administrativa nos fatos relatados. Requereu a extinção da ação pela prescrição, e no mérito requereu que a ação seja rejeitada. Juntou documentos (fls. 1085/1098). GRACIANE TEIXEIRA foi devidamente citada (fl. 1027) e apresentou defesa prévia (fls. 1113/1122). Alegou a ocorrência de prescrição. Afirmou que a sentença do Tribunal de Contas não pode ser utilizada como prova absoluta. Impugnou as alegações da inicial, e a inexistência de improbidade administrativa nos fatos relatados. Requereu a extinção da ação pela prescrição, e no mérito requereu que a ação seja rejeitada. Juntou documentos (fls. 1123).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO foi devidamente citada (fl. 1001) e apresentou contestação (fls. 1126/1141). Alegou a ocorrência de prescrição, bem como a inépcia da inicial, ante a ausência de fatos ímprobos especificamente praticados, e pela descrição genérica e imprecisa dos danos patrimoniais causados pelos requeridos. No mérito, alegou a inoccorrência de improbidade administrativa. Requereu a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos (fls. 1142/1150).

LEONORA DA SILVA ROCHA foi devidamente citada (fl. 1125) e apresentou defesa prévia (fls. 1151/1160). Alegou a ocorrência de prescrição. Afirmou que a sentença do Tribunal de Contas não pode ser utilizada como prova absoluta. Impugnou as alegações da inicial, e a inexistência de improbidade administrativa nos fatos relatados. Requereu a extinção da ação pela prescrição, e no mérito requereu que a ação seja rejeitada. Juntou documentos (fl. 1161).

Foi deferida a notificação por edital da requerida JORDANA APARECIDA DE OLIVEIRA, a qual foi devidamente realizada (fl. 1168). Apresentou defesa prévia (fls. 1169/1207). Alegou a ocorrência de prescrição. Afirmou ter sido responsável tão somente pela elaboração de editais e minutas, recebimento e julgamento de impugnações, abertura e condução de procedimentos licitatórios, análise de

documentações, julgamento acerca da habilitação e classificação, com os respectivos recursos administrativos, e pelo encaminhamento do processo licitatório à Chefe do Executivo, e que, portanto, a fiscalização no cumprimento dos contratos não era de sua responsabilidade. Afirmou ainda que os documentos elaborados eram baseados em modelos aprovados pelo departamento jurídico da Prefeitura. Aduziu ainda que o hospital contratado prestava serviços complementares aos oferecidos diretamente pela Administração Pública. Afirmou não ser responsável pelos aditivos feitos ao contrato, por ter se desligado do contrato em janeiro de 2010. Alegou não estarem presentes os requisitos necessários para a configuração de ato de improbidade administrativa, uma visto não ter ocorrido prejuízo ao Erário, ou dolo ou culpa de sua parte. Requereu a improcedência do pedido. Juntou documentos (fls. 1208/1258). Ante a apresentação de defesa prévia por todos os requeridos, o Ministério Público requereu a intimação do ente federativo, para trazer sua manifestação aos autos (fl. 1264).

O Município se manifestou, informando os cargos que as requeridas exerciam na data dos fatos (fl. 1277). Juntou documentos (fls. 1278/1294).

A municipalidade foi devidamente intimada (fl. 1295).

O Ministério Público apresentou parecer. Manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva por atos de improbidade administrativa apresentada pelos requeridos. Entretanto, entendeu o representante do Ministério Público que o pedido de ressarcimento dos valores ilegalmente pagos pelo ente federativo não está prescrito. Manifestou-se contrariamente à alegação de inépcia da inicial. Opinou pelo deferimento da liminar para a indisponibilidade de bens, bem como pelo recebimento da petição inicial para a indisponibilidade de bens (fls. 1299/1309).

A petição inicial foi recebida. Foi afastada a preliminar de inépcia da petição inicial, sendo acolhida a preliminar de prescrição no tocante à improbidade administrativa, prosseguindo a ação no tocante ao ressarcimento. Foi rejeitado, por fim, o pedido liminar de indisponibilidade de bens (fls. 1310/1312).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO apresentou nova contestação (fls. 1328/1333). Afirmou que a inicial é omissa quanto à concretude do dano, afirmando que o autor presumiu o mesmo, tomando-o como necessário e decorrente de suposta ilegalidade da contratação. Requereu a rejeição do pedido indenizatório. Juntou documentos (fls. 1334/2064).

JORDANA APARECIDA DE OLIVEIRA apresentou contestação (fls. 2065/2080). Alegou ausência de dano ao erário e do dever de ressarcimento pela corrê, de modo que a condenação de qualquer valor acarretaria o enriquecimento ilícito da Administração em detrimento da ré. Afirmou ainda que a atuação da corrê Jordana era delimitada a funções específicas, as quais não incluíam a aquisição de compra e a descrição do objeto da licitação, a dotação orçamentária, e a homologação e adjudicação, não havendo ilegalidade no desempenho das funções que lhe eram atribuídas. Alegou que a corrê, formada em estatística, não possuía obrigação, atribuição ou mesmo meios de verificar se o objeto era adequado do ponto de vista jurídico-constitucional ou se o serviço a ser licitado era ou não de necessidade para o departamento de saúde municipal. Afirmou ainda ausência de qualquer ato doloso por parte da corrê, aduzindo não haver na inicial individualização das condutas ou comprovação de dano ao erário. Requereu a total improcedência do pedido.

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT e LEONORA DA SILVA ROCHA foram devidamente citadas (fl. 2083/2084).

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT DE GOES, GRACIANE TEIXEIRA e LEONORA DA SILVA ROCHA apresentaram contestação (fls. 2085/2103). Afirmaram que o Tribunal de Contas e a inicial não apontaram qualquer prejuízo pecuniário para o Município de Holambra por causa da contratação objeto desta ação. Aduziram que o dano não pode ser presumido em casos como o presente, mas sim efetivo. Requereram, portanto, a total improcedência do pedido inicial.

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO foi devidamente citada (fl. 2110).

A Municipalidade deixou de se manifestar sobre as contestações apresentadas aos autos (fl. 2111).

O Ministério Público apresentou parecer (fls. 2114/2142). Aduziu que o feito

comporta julgamento antecipado do mérito. Quanto ao mérito, entendeu dever a demanda ser julgada parcialmente procedente. No tocante às rés Jordana, Graciane e Leonora, opinou pela não condenação ao ressarcimento do Município de Holambra, em vista das funções desempenhadas pelas corréis, e a ausência de dolo. Quanto à ré Margareti Rose de Oliveira Groot, entendeu o representante do Ministério Público haver dolo em sua conduta por ter a ré conhecimento da impossibilidade de terceirizar integralmente a prestação do serviço público municipal de saúde, autorizando, ainda assim, a abertura de processo licitatório com essa finalidade; por ter a ré homologado e adjudicado a Concorrência Pública nº 001/2009; por ter assinado a contratação da pessoa jurídica Hospital e Maternidade Saint Paulo, hoje Associação Beneficente Samaritano, lançando visto nas notas de empenho referentes à contratação; por não ter suspenso o contrato, mesmo sabendo das irregularidades existentes, apontadas pelo Tribunal de Contas. Ademais, a ré Margareti já havia sido alvo da ação civil pública n. 0002470-58.2014.8.26.0666, por ter contratado o hospital de maneira irregular. Aduz que a contratação por licitação ocorreu tão somente para conferir aparência de legalidade à contratação irregular anterior. No tocante à ré Associação Bom Samaritano, o Ministério Público opinou por sua não condenação ao dever de ressarcimento, uma vez que prestou integralmente os serviços de saúde aos munícipes de Holambra. O Ministério Público opinou favoravelmente à concessão do pedido liminar de indisponibilidade de bens em relação à ré Margareti Rose de Oliveira Groot. Requereu, portanto, a improcedência do pedido em relação às rés Jordana Aparecida de Oliveira, Graciane Teixeira, Leonora da Silva Rocha e Associação Beneficente Samaritano, e a procedência em relação à ré Margareti Rose de Oliveira Groot.

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA requereu o julgamento antecipado do mérito (fls. 2156/2157).

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT DE GOES, GRACIANE TEIXEIRA e LEONORA DA SILVA ROCHA manifestaram-se sobre o parecer do Ministério Público. Afirmaram não ter havido dano ao erário, inexistindo motivo para a aplicação da pena de ressarcimento. Requereram a improcedência da ação em relação à ré Margareti Rose de Oliveira Groot de Goes (fls. 2158/2159).&

MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT DE GOES, GRACIANE TEIXEIRA e LEONORA DA SILVA ROCHA requereram o julgamento antecipado do mérito (fl. 2163).

LEONORA DA SILVA ROCHA requereu a desconsideração de outras manifestações realizadas por outro patrono que não Patrícia Morilla Coelho. No mais, requereu o julgamento antecipado do mérito (fl. 2164).

JORDANA APARECIDA DE OLIVEIRA requereu o julgamento antecipado do mérito, reafirmando o pedido de improcedência do pedido (fls. 2165/2168).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO requereu o julgamento antecipado do mérito (fl. 2173).

O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA requereu novamente o julgamento antecipado do mérito (fls. 2174/2175).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 330, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco: "A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento" (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p.555).

É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, por conta da prova documental coligida aos autos. No mais, versa a demanda matéria de direito, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que compete ao magistrado, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em que se requer, à vista das alegadas ilicitudes cometidas pelos réus no exercício de função

pública (Prefeito e Secretários Municipais de Atibaia/SP), a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.429/92.

Como cediço, a improbidade administrativa pode ser conceituada como sendo o desrespeito, por parte do agente público, ao dever a ele imposto de agir com honestidade no exercício do cargo público que ocupa, sem que se aproveite indevidamente dos poderes e facilidades que deste decorrem, quer seja para exclusivo proveito pessoal, quer seja para benefício de outrem.

Em outras palavras, improbidade administrativa pode ser entendida como “a corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito Democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento de interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e privilégios ilícitos” (Pazzaglini Filho, Marino; Elias Rosa, Márcio Fernando e Fazzio Júnior, Waldo. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996, p. 35).

Disciplinando o tema, a Lei nº 8.429/92 estabelece as consequências ao agente público que pratica atos de improbidade administrativa, precisamente nos seus artigos 9º (atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito), 10 (atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário público), 10-A (atos de improbidade decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário) e 11 (atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública).

Contudo, para que seja possível a responsabilização do agente público por atos de improbidade administrativa, deve haver não apenas provas concretas quanto aos fatos que lhe são imputados, mas, também, demonstração inequívoca do elemento subjetivo de sua conduta, qual seja, o dolo ou, ao menos, a culpa para o caso específico das hipóteses elencadas no rol do artigo 10 da supracitada lei. Nesse sentido o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp nº 21.135/PR, Min Rel Benedito Gonçalves, d.j. 18/04/2013:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. 1. Para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Precedentes: AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/11/2011; REsp 1.130.198/RR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; EREsp 479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 27/9/2010; REsp 1.149.427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/9/2010; e EREsp 875.163/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/6/2010. 2. Agravo regimental não provido.

Desse modo, não é todo e qualquer ato do agente público que pode ser caracterizado como improbidade administrativa, competindo ao autor da ação provar satisfatoriamente a existência da conduta tipificada na Lei nº 8.429/92, bem como o elemento subjetivo do qual estava imbuído o agente quando do seu cometimento.

Em relação às rés JORDANA, GRACIANE e LEONORA, não há nos autos nenhuma comprovação de que tenham atuado de forma dolosa ou culposa no decorrer do procedimento da Concorrência Pública nº 001/2019, praticando assim, os atos de improbidade previstos nos artigos 10, caput e 11, caput e incisos I e II da Lei nº 8.429/1992. Com efeito, JORDANA figurava como presidente da comissão de licitação e juntamente com as demais requeridas, GRACIANE e LEONORA, realizava atividades típicas de organização e administração do edital e do contrato da Concorrência Pública nº 001/2009, como atendimento ao público, conferência de documentos apresentados pelo licitante, classificação, entre outras.

As rés não foram responsáveis pela contratação da Associação Beneficiante Samaritano e não interferiram na elaboração das cláusulas constantes do edital e do

contrato assinado com a corré.

O próprio Departamento Jurídico do Município de Holambra não encontrou qualquer irregularidade no edital e no contrato, o que respaldou o entendimento das rés de que o procedimento seguia de forma escorreita.

A responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade deve se basear em provas concretas quanto aos atos que lhe são imputados, face às graves consequências que afetam a vida do eventual infrator. No mais, para a configuração do ato ímprobo inserto em qualquer dos incisos do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, faz-se necessária esteja presente o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo, ou seja, não é suficiente apenas a culpa, enquanto para a configuração do ato ímprobo inserto no artigo 10 (não mais punível por culpa) é necessário que se comprove o dano ao erário.

Desta forma, cabe ao autor demonstrar, satisfatoriamente, a conduta dolosa que agride a legalidade pública ou demais princípios, a fim de que o administrador seja responsabilizado por ato de improbidade administrativa, no que tange a violação dos princípios da administração pública.

Ademais, a imprecisão na delimitação de conduta concreta dos requeridos quanto a participação direta e individualizada impede a procedência da demanda, decorrente da ausência de descrição de fato que envolva improbidade administrativa em relação a cada agente imputado. Não há como extrair-se a existência de ato de improbidade relativo e tipificado a cada uma das personagens que figuram no polo passivo da relação processual, o que forçosamente faria com que fossem excluídos da lide, com fundamento no art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/1992.

Na ação de improbidade administrativa, a ausência de descrição da conduta do ato ilícito praticado por cada um dos réus afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa dispostos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF.

Nesse cenário, é preciso relembrar do necessário iter de individualização dos atos de improbidade administrativa, rotineiramente esquecidos e que são bem delimitados por Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves (op.cit, pg. 447/451).

(i) primeiro, há que se demonstrar, de forma geral, a incompatibilidade de cada conduta com os princípios regentes da atividade estatal, ou seja, a inobservância do princípio da juridicidade;

(ii) em seguida, deve-se comprovar o elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) da conduta do agente, imprescindível para a caracterização da improbidade, como bem detalhado no segundo artigo desta série;

(iii) terceiro, deve-se verificar os efeitos dos atos perpetrados, para incursão nas hipóteses dos arts. 9º (enriquecimento ilícito), 10 (prejuízo ao erário) ou 11 (ofensa a princípios da Administração Pública) da Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92);

(iv) em quarto lugar, é necessário observar as disposições gerais dos arts. 1º, 2º e 3º da lei 8.429/92, que preveem quem são as pessoas e os atos sujeitos ao regime da Improbidade Administrativa², requisito este indispensável à adequação da via eleita para apenação dos acusados; e

(v) por fim, impõe-se a verificação dos fatos apurados à luz do princípio da proporcionalidade, notadamente para constatação da tipicidade das condutas. A esse respeito, os autores supracitados afirmam que “[e]m um primeiro plano, a sua utilização [Lei 8.429/92] haverá de assumir ares de excepcionalidade, evitando-se que seu emprego seja vulgarizado, terminando por legitimar uma 'atipicidade generalizada'. Como parâmetros a serem seguidos, deve-se observar se é insignificante a lesão aos deveres do cargo ou à consecução dos fins visados e se a conduta apresentava compatibilidade com a realidade social do local em que foi praticada”.

Exatamente pela ausência do iter de individualização da improbidade administrativa e à devida dosimetria das sanções, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que é necessária a análise da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à cominação das penalidades, as quais não devem ser aplicadas indistintamente: faz-se imprescindível, portanto, a individualização das condutas, não se podendo

ultrapassar em espécie ou quantidade o limite da culpabilidade do autor do fato. Do contrário, a inicial acusatória inverte de modo ilegítimo e inaceitável o ônus da prova. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATOS IRREGULARES. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INOBSERVADOS. READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No caso dos autos, o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa contra o ex-Presidente e o ex-Diretor de Administração da Casa da Moeda, com fundamento no art. 11, I, da Lei 8.429/92, em face de supostas irregularidades em contratos firmados sem a realização de processo licitatório. Por ocasião da sentença, o magistrado em primeiro grau de jurisdição julgou procedente o pedido da referida ação para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa e condenar os requeridos, com base no art. 12, III, da Lei 8.429/92. (...) 5. A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 exige que o magistrado considere, no caso concreto, “a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente” (conforme previsão expressa contida no parágrafo único do referido artigo). Assim, é necessária a análise da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do ato de improbidade e à cominação das penalidades, as quais não devem ser aplicadas, indistintamente, de maneira cumulativa. 6. Na hipótese examinada, os recorrentes foram condenados na sentença ao pagamento de multa civil “correspondente a cinco vezes o valor da remuneração recebida pelos Réus à época em que atuavam na Casa da Moeda do Brasil (CMB) no período da contratação irregular, devidamente atualizado até o efetivo pagamento, bem como decretar a perda da função pública que eventualmente exerçam na atualidade, a suspensão dos direitos políticos por três anos e a proibição dos Réus de contratarem com o Poder Público pelo prazo de três anos” (fls. 371/378), o que foi mantido integralmente pela Corte a quo. Assim, não obstante a prática de ato de improbidade administrativa pelos recorrentes, a imposição cumulativa de todas as sanções previstas na referida legislação não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal consideração impõe a redução do valor da multa civil de cinco para três vezes o valor da remuneração, bem como autoriza o afastamento da sanção de suspensão dos direitos políticos dos recorrentes. 7. Provimento parcial dos recursos especiais, tão-somente para readequar as sanções impostas aos recorrentes (REsp 875.425/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 11/02/2009).

Por essa razão, o processo deve ser julgado improcedente, nos termos do artigo 488 do Código de Processo Civil, em relação as requeridas, JORDANA APARECIDA DE OLIVEIRA, GRACIANE TEIXEIRA e LEONORA DA SILVA ROCHA, vez que não restou comprovado que participaram do ato de improbidade em discussão.

Em relação à ré MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, convém ressaltar, que à época da licitação, era Prefeita do Município de Holambra, tendo autorizado a abertura da concorrência pública, a sua homologação e adjudicação, assinando, por fim, a contratação da pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO.

Conforme pontuou o d. Representante do Ministério Público, a ré já tinha ciência de que a contratação, ante o seu caráter inconstitucional, estava sob exame do Tribunal de Contas do Estado, que já havia apontado diversas irregularidades do contrato. Tinha o conhecimento de que as instituições privadas somente poderiam participar de forma complementar do sistema único de saúde, conforme preceitua o artigo 199, §1º da Constituição Federal, porém, optou, frente a tais irregularidades, manter a execução do contrato.

De acordo com o princípio da legalidade, a Administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, instituindo-se um critério de subordinação à lei. Nesse caso, a atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos da autorização contida no

sistema legal.

O princípio da moralidade, por sua vez, impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto.

De outro lado, o princípio da impessoalidade tem por objetivo: (...) a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Neste ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros.

A partir da definição desses princípios, constata-se que a ordem constitucional e as determinações infraconstitucionais são claras no sentido de que não pode haver a transferência integral da saúde pública para entidades privadas, autorizada, apenas, a participação complementar (art. 199, §1º, da CF/88) se comprovada a insuficiência de disponibilidades de recursos públicos (art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90).

Em outras palavras, os serviços objeto da licitação são classificados como essenciais, prestados exclusivamente pela Administração Municipal, vedada a sua terceirização e, pelo que se extrai das provas produzidas no processo, o processo licitatório não tinha por finalidade a complementação dos serviços de saúde prestados diretamente pela municipalidade, o que não encontra amparo na Constituição Federal e nem na legislação infraconstitucional.

E se assim não o bastasse, a ré já havia respondido a outra ação civil pública (autos nº 0002470-58.2014.8.26.0666), pela contratação da mesma instituição - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAMARITANO - sem licitação., que também foi examinado pelo TEC-SP, demonstrando o dolo em sua conduta improba.

No mais, mesmo diante da possibilidade de suspender o contrato em vigência, considerando o apontamento das irregularidades pelo órgão fiscalizador, a ré ainda prorrogou o contrato por diversas vezes, que só foi rescindido a pedido da contratada.

Todavia, ainda que reconhecidos os atos de improbidade concernentes à violação dos princípios da moralidade e da legalidade, tais não são puníveis conforme decisão de fls.1310/1312, em vista da prescrição.

Em relação ao ato de improbidade previsto no artigo 10 da Lei 8.429/1992, já restou pacificado pela jurisprudência das Cortes Superiores, a sua imprescritibilidade.

Entretanto, em que pese o entendimento do Parquet, além do dolo, necessária a presença do efetivo dano ao erário, como se vê neste exemplares julgados:

ADMINISTRATIVO. SIMULAÇÃO DE LICITAÇÃO. TIPIFICAÇÃO COMO ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO (ARTIGO 10 DA LEI 9.429/92). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. PRECEDENTES DO STJ. ATO DE IMPROBIDADE QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12, INCISO III, DA LEI 8.429/92. ANÁLISE DA GRAVIDADE DO FATO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. O enquadramento do ato de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente na categoria de improbidade administrativa ensejadora de prejuízo ao Erário (inciso VIII do art. 10 da Lei 8.429/92) reclama a comprovação do efetivo dano ao patrimônio público, cuja preservação configura o objeto da tutela normativa (Precedentes do STJ). (...). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido (Resp. 1.169.153/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 24.8.2011).

ADMINISTRATIVO.

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO.

MODALIDADE CULPOSA. POSSIBILIDADE. FAVORECIMENTO PESSOAL. TERCEIRO BENEFICIÁRIO.

REQUISITOS CONFIGURADOS. INCURSAO NAS PREVISÕES DA LEI

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei 8.429/92 exige a comprovação do dano ao erário e a existência de dolo ou culpa do agente. Precedentes. (...). 5. Recurso especial provido em parte (Resp 1.127.143/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 3.8.2010).

In casu, contudo, o requerente não esmerou a demonstração do dano. Portanto, em razão da ausência de comprovação do dano ao erário municipal não é possível a condenação em ressarcimento, pela ré, dos valores pagos.

No mais, o próprio Ministério Público opinou pela improcedência da ação em relação à corré ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO, uma vez que os serviços foram integralmente prestados. Não há provas de que os valores cobrados pela requerida "eram, por exemplo, superiores aos de mercado ou que os serviços de saúde foram mal prestados ou interrompidos durante a prestação" (fls.2125). .

Não há indicação pelas partes qual ato previsto em um dos 22 (vinte e dois) incisos do artigo 10 da Lei de Improbidade a ré teria cometido, nem ao menos que a ação dolosa ensejou "efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei"

Até mesmo para a aplicação da pena, é necessário ao magistrado o conhecimento da extensão do dano causado, que não restou demonstrada nos autos.

Não havendo prova de dano ao erário, afasta-se a sanção de ressarcimento prevista na primeira parte do inciso III do art. 12 da Lei 8.429 /92. As demais encontram-se afastada ante o reconhecimento da prescrição.

São esses os fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente aplicados no caso, suficientes ao julgamento da presente lide. Em que pese a aparente relevância dos demais argumentos deduzidos pelas partes no processo, referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde da causa, incapazes de infirmarem a conclusão adotada na presente sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi

(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código Processo Civil. Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.

Decorrido o prazo para a interposição de recursos, com ou sem interposição voluntária, subam os autos para o reexame necessário, por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 (REsp 1108542/SC).

Oportunamente arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas anotações

P.I.C.

Artur Nogueira, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA